

УДК 346.26

ББК 67.404

НЕЧУХАЕВА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНАЗаместитель генерального директора
по правовым вопросам ООО «ГП Идея»
e-mail: nechukhaeva.olesya@gmail.com**NECHUKHAeva OLESYA VLADIMIROVNA**Chief deputy on legal issues
ООО «GP Idea»
e-mail: nechukhaeva.olesya@gmail.com

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ DUE DILIGENCE

HISTORICAL ASPECTS OF DUE DILIGENCE LEGAL IMPLEMENTATION

Аннотация. Due diligence как практика имел, имеет и будет иметь важное значение при совершении сделок. Его актуальность будет возрастать все больше в связи с упрощением совершения процедур активного инвестирования и сделок купли-продажи как на местных, так и международных рынках. Отдельную актуальность обретает понимание и стандартизация указанной практики. Ключевая проблема отсутствия стандартов данной практики и ее возрастающая актуальность заставляют нас обратиться к истории ее возникновения в различных правовых формах, исторических и юридических конструкциях.

В данной статье рассматриваются ключевые моменты упоминания due diligence, в частности в римском праве, общем праве, международном праве, рынке ценных бумаг, банковском праве.

Выводами статьи отметим, что несмотря на длительный период существования due diligence и обращения к нему как при совершении сделок, так и в международных отношениях следует приложить должную осмотрительность к его описанию и созданию стандартов.

Ключевые слова: due diligence, дью дилидженс, должная осмотрительность, должная внимательность, должное усердие, должная заботливость, всестороннее исследование, проверка чистоты сделки, аудит, стандартизация.

Abstract. Due diligence as a practice has been, is and will be important when making transactions. Its relevance will increase more and more as active investment and sales procedures in both local and international markets are simplified. The understanding and standardization of this practice is gaining particular relevance. The key problem of the lack of standards of this practice and its increasing relevance makes us turn to the history of its emergence in various legal forms, historical and legal constructions.

This article deals with key points of reference to due diligence, in particular in Roman law, general law, international law, the securities market, banking law.

The conclusions of the article note that, despite the long period of due diligence existence and referring to it both in transactions and in international relations, due diligence should be applied to its description and the creation of standards.

Keywords: due diligence, audit, standardization.

В настоящее время такое понятие, как *due diligence* (дью дилидженс), в основном, на слуху лишь у практикующих специалистов. Теоретики же либо просто с ним не знакомы, либо расходятся в понимании его сущности.

Бесспорным является тот факт, что сегодня консалтинговые компании активно популяризируют услуги по проведению *due diligence*, постоянно используя данный инструмент в своей работе. По логике такая обширная применительная практика должна помогать *due diligence* стремительно развиваться. Однако отсутствие единого образа в понимании и реализации *due diligence* вынуждает каждого отдельного специалиста или компанию прибегать к творческому подходу при его толковании и проведении, например, разрабатывая с нуля собственные методики и процедуры, что, в свою очередь, наоборот, создает искусственные барьеры, сдерживающие его популяризацию.

Даже в научной литературе можно встретить различные подходы к толкованию термина *due diligence*: в широком смысле, в узком смысле, а также буквальный перевод.

Под *due diligence*, как правило, понимают в широком смысле «всестороннее исследование» [1, с. 144; 2, с. 360], «проверку чистоты сделки» [3, с. 86] и «исследование инвестиционной привлекательности компании» [4, с. 167], а в узком — проверку [5, с. 277], экспертизу [6, с. 193] и аудит [7, с. 163].

Отдельного внимания заслуживает частота использования буквального перевода *due diligence* с английского языка.

Проведенный анализ показал, что наиболее часто специалисты прибегают именно к нему. В литературе можно встретить большое количество вариантов перевода, однако, подавляющее большинство авторов используют следующие: должная осмотрительность [8, с. 185], добросовестность

[9, с. 293], старательность [10, с. 56], усердие [11, с. 144], заботливость [12, с. 105].

Именно буквальный перевод термина дает возможность воссоздать исторический процесс возникновения, становления и развития *due diligence*.

Проведенный анализ научной литературы показал, что у авторов отсутствует единое мнение как о периоде происхождения, так и дате первого упоминания данного понятия, которое, безусловно, по своей сущности значительно отличалось от современного понимания.

По мнению различных авторов *due diligence* как понятие впервые появился в следующих правовых конструкциях:

- римское право;
- общее право;
- международное право;
- рынок ценных бумаг;
- банковское право.

В связи с чем хотелось бы рассмотреть каждый из таких вариантов более подробно.

РИМСКОЕ ПРАВО

Некоторыми авторами высказывается мнение, что зачатки понимания концепции *due diligence* возникли еще во времена римского права.

Так, в научной литературе бытуют две точки зрения на появление концепции *due diligence* в разрезе этого периода.

Первая точка зрения подразумевает, что к появлению концепции *due diligence* привел принцип *caveat emptor*, в переводе с латинского — «пусть покупатель остерегается» [13, с. 18]. Согласно ему именно покупатель нес риски недостатков покупки при совершении сделок купли-продажи, что стимулировало его быть осмотрительным при совершении сделки.

Согласно второй принцип римского права *diligentia*, в переводе означающий «заботливость, внимательность», привел к появлению концепции «*diligence*» [14, с. 4].

ОБЩЕЕ / ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПРАВО

Иной подход связывает возникновение концепции *due diligence* с общим правом (прецедентным).

Некоторые авторы полагают, что изначальное использование понятия *diligence* (усердия (заботливости, осмотрительности)) можно датировать началом XVII века. А уже в XVIII веке использовались три его вида:

- распространенное или обычное;
- высокое или большое (чрезвычайное усердие);
- низкое или небольшое.

По мнению данных авторов именно уровень распространенного или обычного усердия соответствует терминам «*due*», который в переводе с английского языка означает «должный», и «*due diligence*», в переводе — «должное усердие, должная осмотрительность»

Так, прецедентное право США подразумевает обязанность сторон сделки проявлять общее усердие (заботливость, осмотрительность). А больший уровень усердия (осмотрительности, заботы) снизит риск вероятности наступления негативных последствий в будущем. Таким образом, сторонам сделки не возбраняется использовать строгий «высокий римский» стандарт [14, с. 3–4].

Иными словами, существует прямая пропорциональность: прикладывание большего количества усердия (заботливости, осмотрительности) сторонами на этапе подготовки сделки ведет к уменьшению вероятности реализации рисков в будущем.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Стандарт *due diligence* имеет довольно длинную историю в международном праве. В трудах юристов XVII века, включая Гуго Гроция, Ричарда Зуша и Самуэля Пуфендорфа, упоминалась обязанность суверенов по предотвращению причинения вреда иностранным гражданам, по привлечению

частных лиц, совершивших акты насилия в отношении иностранцев, к наказанию и гарантированию компенсации. Данный взгляд на стандарт усердия (заботливости, осмотрительности), подлежащий соблюдению государственными властями, расширялся и разрабатывался на протяжении XVIII, XIX и начала XX веков, в частности, в контексте арбитражных решений относительно ответственности за несоблюдение защиты иностранцев и их собственности от вреда в результате частных посягательств.

В то время как в каждом из этих арбитражных решений исследовались фактические обстоятельства отдельного дела и решался вопрос о том, соблюдало ли государство необходимый уровень усердия (заботливости, осмотрительности) относительно предотвращения причинения вреда индивиду или собственности, не было достигнуто согласия по вопросу о том, что собой представляют определенные характеристики должного усердия (заботливости, осмотрительности) [15, с. 48].

Как отмечал Ян Браунли в отношении принципов, применимых к государственной ответственности за причинение вреда иностранному гражданину или его собственности в результате актов насилия и восстания: «Писатели соглашаются, что правило неответственности не может применяться там, где государство не проявило должного усердия (заботливости, осмотрительности). Тем не менее, решения судов и других источников не предлагают определения «*due diligence*». Очевидно, что слишком доктринальное определение не будет подходящим с тех пор, как применяется стандарт, варьирующийся от обстоятельств. Однако, если термин «*due diligence*» будет взят для обозначения объективно высокого стандарта поведения, то исключения подавят правило» [16, с. 438].

Дальнейшее упоминание содержится в Вашингтонском договоре от 8 мая 1871 года, сторонами которого являются Вели-

кобритания и Соединенные Штаты Америки. Так, согласно шестой статье данного договора в обязанности нейтрального правительства входит «употреблять все свое старание (*d'user de toute due diligence*) для того, чтобы не допускать в пределах своей юрисдикции снаряжения и вооружения кораблей (*equipement et armement de tout vaisseau*), назначаемых, но по его мнению, к крейсированию или враждебным действиям против дружественного для него государства, а также прилагать все старание к тому, чтобы воспрепятствовать отъезду из пределов своей территории (*le depart de sa juridiction*) таких кораблей, которые в целом или в частях были приспособлены в пределах его юрисдикции, к военным целям» [17, с. 26–27].

Также Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года содержит указание на обязательство должной осмотрительности у государств: «гарантировать соответствие действий подрядчиков, за которых они поручились, условиям договора...Исполнять обязательство «должной осмотрительности» государство-поручитель может только в пределах своей правовой системы путем принятия законов и постановлений, а также применения административных мер, которые должны быть «в разумных пределах»» [18, с. 39].

СФЕРА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Подавляющее большинство авторов, изучавших историю становления *due diligence*, считают, что Закон о ценных бумагах 1933 года (США) заложил подход к современному пониманию концепции *due diligence*. И действительно мы можем встретить такой термин в секции 11(b)(3) данного нормативного правового акта. Указанная норма гарантирует, что лица, проявляющие должное усердие (заботливость, осмотрительность) при исследовании данных проспекта эмиссии ценных бумаг, получают защиту.

По мнению авторов именно этот процесс оценки в дальнейшем получил название «*due diligence*» [19, с. 157].

Вы можете также встретить термин и в статьях 4 (с)(3)(A) (Исключения по сделкам), 7 (с)(2)(B) (Информация, требуемая в заявлении о регистрации) Закона о ценных бумагах 1933 года.

Далее законодатель прибегает к использованию данного термина в ряде секций Закона о торговле ценными бумагами 1934 года (США): 13 (p)(1), 15E (s)(3), 15E (s)(4), 15G (c)(1) и 17A (g).

К сожалению, законодатель пошел лишь по пути неоднократного упоминания термина *due diligence* в указанных нормативных правовых актах без дачи ему определения, не говоря уже о последующем раскрытии его содержания.

БАНКОВСКАЯ СФЕРА

В 1977 году было подписано Соглашение швейцарских банков о должной проверке (*The Swiss Bank's Due Diligence Agreement*). Считается, именно оно содержит применяемые сегодня стандарты *due diligence* при проверке клиентов [20, с. 26].

На данный момент *due diligence* применяется повсеместно.

В заключении статьи отметим, что *due diligence* существует давно и, возможно, даже дольше, чем мы можем проследить по письменным источникам, так как данная практика напрямую связана с управлением рисками при совершении сделок и даже выходит за пределы рамок совершения сделок в международных отношениях. Вопрос, связанный с *due diligence*, будет оставаться актуальным до тех пор, пока существуют понятия сделок, купли-продажи, инвестирования, где одна сторона полагается на добросовестность другой стороны при взаимоотношениях. Изменение скорости транзакций и сокращение географических границ делает вопросы надлежащей

осмотрительности более размытыми, стороны сделки могут находиться в разных правовых полях и традициях и по-разному понимать данный термин и его наполнение.

В связи с чем хочется еще раз отметить, что вопрос определения данного термина и стандартизации практики в целом будет становиться все более востребованным.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Аксенова Ж. А. Due diligence — процедура всестороннего исследования деятельности компании // НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ. Сборник материалов научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава Сыктывкарского лесного института по итогам научно-исследовательской работы в 2008 году. — 2009. — С. 144–148.
2. Царев В. В., Кантарович А. А., Черныш В. В. Оценка конкурентоспособности предприятий (организаций): теория и методология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям экономики и управления. — М. : ЮНИТИ, — 2008. — 799 с.
3. Антонова Н. А. Due diligence в условиях актуарного учета: исторический аспект // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. — 2014. — № 2 (141). — С. 83–90.
4. Стяжкина И. В. Исследование инвестиционной привлекательности компании и его отличительные особенности // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. — 2017. — № 5 (107). — С. 166–171.
5. Организация деятельности коммерческого банка: учебник / Под ред. Е.А. Звоновой. — М. : ИНФРА-М, 2012. — 632 с.
6. Эффективное государственное управление в условиях инновационной экономики: финансовые аспекты: монография / Под ред. С.Н. Сильвесторова, И.Н. Рыковой. — М. : Дашков и К°, 2011. — 349 с.
7. Рогова Е. М., Ткаченко Е. А., Фияксель Э. А. Венчурный менеджмент: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент». — М. : Изд. дом Высш. шк. экономики, — 2011. — 438 с.
8. Андреев В. К., Лаптев В. А. Корпоративное право современной России: монография. — М. : Проспект, 2016. — 239 с.
9. Современные проблемы управления в условиях информационного общества: научное издание. Научная специальность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / Под ред. Н. В. Тихомирова. — М. : ЮНИТИ : МЭСИ, 2012. — 751 с.
10. Красова Л. Г. Практика антикризисного управления. — М. : Лаборатория Книги, — 2010. — 117 с.
11. Барышев М. А. Инвестиционная деятельность государства: проблемы финансово-правового регулирования: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.14. — Саратов, — 2010.
12. Толстых В. Л. Курс международного права: учебник. — М. : Волтерс Клувер, 2009. — 1031 с.
13. Кучер А. Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект. — М. : Статут, 2005. — 361 с.
14. Lajoux A. R., Elson C. M. The Art of M&A Due Diligence: Navigating Critical Steps & Uncovering Crucial Data. — New York : McGraw-Hill Education, 2010. — 480 с.
15. Due Diligence and Its Application to Protect Women from Violence / Под ред. С. Benninger-Budel. — Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2008. — 296 с.
16. Brownlie I. Principles of Public International Law. — New York : Oxford University Press, 2008. — 784 с.
17. Камаровский Л. А. Первое трехлетие института международного права. 1873–1876. — М. : тип. Индриха, 1877. — 106 с.
18. Цит. по: Шинкарецкая Г. Г. Общее наследие человечества и мировой рынок // Международная научно-практическая конференция «Тункинские чтения»: Сборник докладов и статей. — 2013. № 3. — С. 27–41.

19. Методы и инструменты управления инновационным развитием промышленных предприятий: монография / Под ред. И.Л. Туккеля. — СПб. : БХВ-Петербург, 2013. — 208 с.
20. Арабян К. К. Организация и проведение аудиторской проверки: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит». — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ, 2015. — 550 с.

REFERENCES:

1. Aksenova Zh. A. Due diligence-a procedure for a comprehensive study of the company's activities // SCIENTIFIC READINGS. Collection of materials of the scientific and practical conference of the faculty of the Syktyvkar Forest Institute based on the results of research work in 2008. 2009. pp. 144–148.
2. Tsarev V. V., Kantarovich A. A., Chernysh V. V. Assessment of the competitiveness of enterprises (organizations): theory and methodology: a textbook for students of higher educational institutions studying in the specialties of economics and management. — Moscow: UNITY, 2008. — 799 p.
3. Antonova N. A. Due diligence in the conditions of actuarial accounting: historical aspect // Bulletin of the Adygea State University. Series 5: Economics. 2014. No. 2 (141). pp. 83-90.
4. Styazhkina I. V. Research of the investment attractiveness of the company and its distinctive features // Proceedings of the St. Petersburg State University of Economics. 2017. No. 5 (107). pp. 166–171.
5. Organization of the activities of a commercial bank: textbook / Edited by E. A. Zvonova. — M.: INFRA-M, 2012. — 632 p.
6. Effective public administration in the conditions of an innovative economy: financial aspects: monograph / Edited by S. N. Silvestorov, I. N. Rykova. — M.: Dashkov and Co., 2011. — 349 p.
7. Rogova E. M., Tkachenko E. A., Fiyaksel E. A. Venture management: a textbook for students of higher educational institutions studying in the areas of training "Economics" and "Management". — M.: Publishing House of Higher School of Economics, 2011. — 438 p.
8. Andreev V. K., Laptev V. A. Corporate law of modern Russia: monograph. — Moscow: Prospekt, 2016. — 239 p.
9. Modern problems of management in the information society: a scientific publication. Scientific specialty 08.00.05 "Economics and management of the national economy" / Ed. N. V. Tikhomirova. — M.: UNITY: MESI, 2012. — 751 p.
10. Krasova L. G. The practice of anti-crisis management. — M.: Laboratory Books, 2010. — 117 p.
11. Baryshev M. A. Investment activity of the state: problems of financial and legal regulation: dis. ... cand. jurid. sciences': 12.00.14. Saratov, 2010.
12. Tolstykh V. L. Course of international law: textbook. — Moscow: Volters Kluver, 2009. — 1031 p.
13. Kucher A. N. Theory and practice of the pre-contractual stage: legal aspect. — Moscow: Statute, 2005. — 361 p.
14. Lajoux A. R., Elson C. M. The Art of M&A Due Diligence: Navigating Critical Steps & Uncovering Crucial Data. — New York : McGraw-Hill Education, 2010. — 480 p.
15. Due Diligence and Its Application to Protect Women from Violence / Edited by C. Benninger-Budel. — Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2008. — 296 p.
16. Brownlie I. Principles of Public International Law. — New York : Oxford University Press, 2008. — 784 c.
17. Kamarovsky L. A. The first three-year anniversary of the Institute of International Law. 1873–1876. — M.: type. Indrikha, 1877. — 106 p.
18. Cit. according to: Shinkaretskaya G. G. The common heritage of mankind and the world market // International scientific and practical conference "Tunka readings": A collection of reports and articles. 2013. No. 3. pp. 27–41.
19. Methods and tools for managing the innovative development of industrial enterprises: monograph / Edited by I. L. Tukkel. — St. Petersburg : BHV-Petersburg, 2013. — 208 p.
20. Arabyan K. K. Organization and conduct of an audit: a textbook for university students studying in the specialties "Accounting, analysis and audit", "Finance and Credit". — 2nd ed., reprint. and additional-M.: UNITY, 2015. — 550 p.